

1500351-76.2020.8.26.0557
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES
Comarca: Viradouro
Foro: Foro de Viradouro
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 21/07/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VITOR AFONSO DE MELLO RICIOLE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Vistos e examinados os presentes autos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Viradouro
Foro de Viradouro
Vara Única
Rua José Borelli, 10, Viradouro - SP - cep 14740-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença nos autos sob o n. 1500351-76.2020.8.26.0557 - lauda de
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500351-76.2020.8.26.0557
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VITOR AFONSO DE MELLO RICIOLE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Vistos e examinados os presentes autos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia VITOR AFONSO DE MELLO RICIOLE, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que, no dia 22 de maio de 2020, por volta de 20h50, na Rua São Pedro, nº 112, Bairro Vila São Pedro, nesta

cidade e comarca, ele trazia consigo, para fins de tráfico, 15,47 gramas de cocaína, acondicionados em 31 microtubos plásticos, tratando-se de substância que causa dependência física e química, sendo que o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante (f. 01/05) e teve a prisão preventiva decretada, conforme decisão de f. 46/49.

Aos 29 de maio de 2020, por força da r. decisão proferida pela Colenda 16ª Câmara de Direito Criminal, em sede de habeas corpus (f. 79/84 e 119/123), o acusado foi colocado em liberdade.

O acusado foi notificado (f. 136) e apresentou defesa preliminar (f. 140/145).

A denúncia foi recebida no dia 28 de janeiro de 2021 pela decisão de f. 152/153 e o réu foi citado (fl. 168).

Na audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas e, por fim, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada, admitida a incidência da causa de diminuição de pena do "tráfico privilegiado".

A Defesa, por sua vez, pediu a aplicação da pena mínima e os benefícios penais cabíveis.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a análise da prova oral produzida.

A testemunha REGINALDO FELIX DE ALMEIDA, policial militar, ouvido na fase inquisitiva (f. 02), afirmou: "Em patrulhamento pela Rua: São Pedro, lugar este conhecido pela frequência de usuários e traficantes de drogas, avistamos o indiciado Vitor parado com uma bicicleta, o qual ao avistar a viatura demonstrou nervosismo, então a gente o abordou, retido, o indiciado começou a se apavorar e notei que ele estava com uma sacola plástica amarrada na mão, procedemos a uma busca pessoal em suas vestes, porém nada de ilícito foi encontrado, após vasculhei a sacola que estava amarrada na mão do indiciado e encontrei trinta e um pinos de cocaína, além da quantia, em notas diversas, de R\$ 1.610,00 reais, perguntei para o indiciado qual a procedência da droga e do dinheiro, ele me contou que o dinheiro seria fruto de um poupança de trabalho e a droga teria encontrado no córrego pela Av. João dos Santos Filho, o indiciado já era conhecido por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas, dei voz de prisão para ele, em seguida fomos até a residência do indiciado situada na Rua: Hugo de Oliveira Carvalho, n. 760, em busca no imóvel encontramos no quarto dele a quantia de R\$ 2.720,00 dentro de uma sacola preta em uma gaveta no guarda-roupas, ainda, no quarto, em outra gaveta encontramos uma sacola azul com a quantia de R\$ 1.987,00 reais. Indagado, o indiciado insistiu que os valores seriam fruto do seu trabalho, mas constatei que as notas diversas, de cem, de cinquenta, vinte, dez, cinco e dois reais, em seguida nós o encaminhamento ao pronto socorro para passar por exame de corpo de delito e depois o apresentamos aqui na Delegacia".

Em juízo, disse que faziam patrulhamento e o acusado demonstrou nervosismo ao ver os policiais; ele tinha uma sacola na mão; ele foi revistado e foi encontrada cocaína na sacola; ele autorizou a entrada na casa dele; na casa dele, encontraram dois volumes de dinheiro; o acusado disse que encontrou a droga no córrego de uma avenida; o acusado frequentava muito local que era ponto de tráfico, por isso era suspeito; o acusado já havia sido abordado há algum tempo.

A testemunha DALTON FERNANDES SARANSO, policial militar, ouvido na fase investigativa (f. 03), declarou: "De serviço, na companhia do PM Reginaldo, em patrulhamento pela Rua: São Pedro, lugar conhecido pela frequência de usuários e traficantes de drogas na cidade, vimos o indiciado Vitor parado com uma bicicleta, quando ele avistou a viatura ficou aflito, a gente o abordou, detido, o indiciado começou a ficar mais apavorado e estava com uma sacola plástica amarrada na mão, o PM Reginaldo procedeu a uma busca pessoal em suas vestes, no entanto nada de

ilícito foi encontrado, Reginaldo vasculhou a sacola que estava amarrada na mão do indiciado e encontrou trinta e um pinos de cocaína, bem como a quantia de R\$ 1.610,00 reais, Reginaldo perguntou para o indiciado qual a procedência da droga e do dinheiro, ele disse que o dinheiro seria fruto de um poupança de bicos e a droga teria encontrado no córrego pela Av. João dos Santos Filho, o indiciado Vítor seria conhecido nos meios por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas, Reginaldo deu voz de prisão para o indiciado, em seguida fomos até a residência dele situada na Rua: Hugo de Oliveira Carvalho, n. 760, em busca no imóvel do indiciado, o PM Reginaldo encontrou no quarto dele a quantia de R\$ 2.720,00, dentro de uma sacola preta, em uma gaveta no guarda-roupas, no quarto, em outra gaveta Reginaldo encontrou uma sacola azul com a quantia de R\$ 1.987,00 reais. Perguntado, o indiciado insistiu que os valores seriam fruto do seu trabalho". Em juízo, disse que fazia patrulhamento, quando viu o acusado de costas; ao observar a viatura, "sentimos uma reação nele de preocupação"; o companheiro PM REGINALDO desceu primeiro e abordou o acusado; revistado, não foi encontrado entorpecente; na bicicleta dele havia uma sacola; olhando a sacola, que estava no guidão da bicicleta, localizou pinos de cocaína; não se recorda do valor em dinheiro que estava apreendido, "mas foi um dinheiro bom"; após a leitura da denúncia, corrigiu-se e informou que a sacola estava na mão do acusado ao descer da bicicleta; seu companheiro que abordou o acusado; foram até a casa do acusado; conversaram com ele e ele autorizou a ir até a casa dele; não foram localizadas outras drogas no local; foram localizados dois volumes em dinheiro; o acusado disse que tinha encontrado as drogas em uma distância considerável; ele afirmou que o dinheiro era do trabalho dele; ele não disse o que faria com a droga.

A testemunha MARIA APARECIDA DE CASTRO SILVA, em Juízo, disse que é aposentada; na época dos fatos, já era aposentada; era vizinha do acusado; acredita que morou próximo a ele por três a quatro anos; costumava ficar sentada na porta da casa junto ao seu marido durante a noite; dava para ver a casa do acusado; não via movimentação estranha de pessoas; nunca ouviu boatos que o acusado vendesse droga; não presenciou o dia da prisão do acusado.

A testemunha JOAO ROBERTO THOMAZ DE MELLO, em Juízo, disse que é pedreiro; o acusado trabalhava ajudando o depoente; sempre que o acusado estava sem registro em carteira, trabalhava com o depoente; ele ganhava cerca de R\$ 500,00 por seis dias de trabalho durante uma semana; a testemunha JOAQUIM tem um sítio e faz vassouras; o acusado também prestava serviços para ele; o depoente pagava o acusado pela diária, mas o pagamento era feito semanalmente; dependia do que o depoente ganhava; a diária era entre R\$ 90 e R\$ 95.

O acusado, perante a autoridade policial (f. 04), respondeu: "Hoje, por volta das 16:00 horas, eu estava rapando a varanda de uma casa onde vou morar, um rapaz passou e ergueu uma folha de coqueiro velha e pôs debaixo algo, curioso eu fui ver o que tinha, não vi o que era e guardei comigo. Tomei um banho em casa e iria sumir com aquilo que peguei, depois saí e vi um pessoal fumando maconha e perguntei se eles queriam aquilo que eu tinha encontrado, eles disseram que não, o pessoal me disse que tinha um povo mais a frente que mexia com esses trem, mas não deu tempo, a Polícia me abordou. O dinheiro encontrado era do meu trabalho que eu junto para poder me manter. Não sou traficante e o dinheiro é fruto do meu trabalho. Em uma sacola, no meu quarto, tinha dois setecentos e vinte que eu não podia gastar, nem a pau, pois iria pagar o cheque da minha avó que vence dia primeiro, a força e as quatro contas de água atrasadas. O dinheiro que foi pego comigo na hora da abordagem eu iria usar para pagar os pintores e o cara que iria montar móveis". Em juízo, admite os fatos; disse que estava apertado de dinheiro; tem duas filhas; estava pressionado pela ex-mulher a pagar pensão atrasada; começou a pandemia; estava sem serviço; "fui fazer essa cagada"; comprou a droga na cidade mesmo; o depoente estava com a droga há oito dias; quando acabasse, iria atrás de serviço; o depoente está trabalhando com registro em carteira há mais de um ano na fábrica de sacolas.

Pois bem.

Preliminarmente, entendo que a apreensão do dinheiro na residência do acusado, no valor de R\$ 2.707,00, foi ilícita. Explico.

O artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Conclui-se, pois, que o ingresso na residência só é possível em caso de flagrante delito, por determinação judicial ou com o consentimento válido do morador. Contudo, nenhuma das hipóteses estava presente no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, julgando o HC n. 598.051/SP, definiu as exigências, em termos de standard probatório (standards de prova “são critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado” - BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. São Paulo: RT, 2019, p. 236), para o ingresso policial em domicílio de pessoa suspeita sem mandado judicial, ou seja, para a devida proteção à garantia da inviolabilidade de domicílio, são necessárias providências mínimas.

Para o ingresso na residência em hipótese de flagrante delito, é necessária a existência de fundadas razões (justa causa) aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

A Corte Federal definiu que o tráfico ilícito de entorpecentes, embora seja classificado como crime permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontram as drogas. A entrada somente será permitida em situações de urgências, quando for possível concluir de modo objetivo e concreto que o atraso decorrente da obtenção do mandado judicial possa permitir a destruição ou ocultação da prova do crime ou da própria droga.

Para o ingresso na residência mediante consentimento do morador, é necessário que a autorização seja assinada pelo morador e por testemunhas que atestem que o morador consentiu com o ingresso e que acompanhem a busca realizada, o que deverá ser registrado em auto circunstanciado, em estrita observância ao que determina o art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal, que se aplica a qualquer forma de busca e apreensão domiciliar, com ou sem mandado judicial; ou que a diligência seja integralmente registrada em vídeo e áudio, sem cortes ou edição, especialmente se não for possível a assinatura da autorização escrita.

O consentimento para entrada na residência pelo morador deve ser voluntário e livre de qualquer constrangimento ou coação. Vale ressaltar que, havendo dúvida, a prova da existência e validade do consentimento é ônus da prova que recai sobre o Estado, personificado no processo pelo Ministério Público. Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo” (HC n. 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021).

Passando à análise do caso concreto, a ausência de autorização judicial é incontroversa, eis que o competente mandado de busca e apreensão em momento algum foi solicitado.

Também não ficou demonstrado que houve consentimento válido externado pelo morador. Segundo os policiais militares condutores, o acusado foi encontrando trazendo consigo drogas em via pública e, a partir disso, os policiais militares decidiram revistar também a residência do acusado, alegando que ele consentiu com isto. Entretanto, o suposto consentimento do(s) morador(es) para entrada na residência não foi confirmado de qualquer modo, em Juízo ou fora dele.

Ainda que haja elemento de prova em sentido contrário – neste sentido está o depoimento dos policiais militares – não estão presentes elementos suficientes para convencer o Juízo da validade do consentimento. Sobre o tema, ensinam os processualistas PIERPAOLO CRUZ BOTTINI e ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO:

Em muitos casos, policiais adentram residências particulares, sem que presentes quaisquer destas situações excepcionais, sob o pretexto de terem obtido o consentimento do morador. (...) Importante analisar a situação do dito

'consentimento' do morador, apto a excepcionar a regra da inviolabilidade do domicílio e autorizar a busca sem mandado judicial. Sabe-se que, nas buscas domiciliares, há um conflito de interesses em jogo – a busca da verdade, para realização da justiça criminal, e a preservação da intimidade e da inviolabilidade do domicílio. O consentimento do morador aparece como primeira forma de solução desse conflito. No entanto, é preciso cautela na sua análise, sempre diante das circunstâncias de obtenção da prova e da atuação da autoridade policial. (...) O consentimento, porém, deve ser real e livre, desprovido de vícios como o erro, violência ou intimidação. Evidentemente que, em cada caso concreto, o consentimento do morador deve ser analisado com cautela e nunca presumido, especialmente para que se evitem abusos da autoridade policial. (...) O TJRS recentemente destacou a invalidade do consentimento de pessoa investigada por tráfico de drogas. Na ocasião, o Desembargador relator pontuou: 'Não existe previsão legal para a busca domiciliar a partir da permissão informal do proprietário. Do consentimento a que se refere o art. 5.º, XI, da CF não se infere que poderão ser realizadas buscas sem determinação judicial, apenas sob a anuência do morador. Se assim fosse, veríamos diante de um quadro temerário, no qual os mandados de busca e apreensão seriam dispensáveis, já que polícia sempre poderia conseguir, extrajudicialmente, o 'consentimento' do proprietário. Afinal, é de se ter em conta que, nas circunstâncias descritas nos autos esse aval foi dado sob constrangimento' (Ap 70058172628, Rel. Des. Diógenes V. Hassan Ribeiro, 3.ª Câmara Criminal, DJ 24.06.2014). Dessarte, se há o consentimento do morador para buscas domiciliares, algumas questões devem ser bem refletidas: (I) forma do consentimento; (II) pessoa que consente e seu grau de esclarecimento sobre as implicações da medida. Sobre a forma do consentimento, deve ser expresso e jamais presumido, sendo que não há previsão legal de forma especial. (...). No tocante à pessoa que consente, deve ser aquele titular do direito à inviolabilidade do domicílio. A doutrina destaca que a permissão deve ser do próprio sujeito da medida de busca e apreensão ou de outra pessoa que possa, legitimamente, representá-lo. Ressalvas são feitas, ainda, às habitações coletivas, em que o consentimento por um dos moradores não autoriza a busca na casa ou aposento de terceiros. No entanto, maior relevo tem a questão do grau de esclarecimento do morador que consentiu na realização da busca e apreensão. Para que se solucione o conflito de interesses – busca da verdade para realização da justiça e inviolabilidade do domicílio – por via consensual, é necessário que aquele que consente tenha pleno conhecimento das circunstâncias e consequências da realização da busca domiciliar, bem como que isso seja documentado. No ponto, não há previsão legal. Contudo, tratando-se de medida que pode implicar a produção de prova contra o próprio morador que consente com a busca, para que ele decida de forma justa e válida se franqueará a entrada em sua residência, necessário que no mínimo lhe sejam esclarecidos seus direitos e o alcance da inviolabilidade do domicílio, bem como as consequências da realização da busca domiciliar. A mesma lógica e o mesmo cuidado são observados nos procedimentos de interrogatórios, tanto judicial quanto policial, a fim de garantir o direito da pessoa de não produzir prova contra si (deriva das previsões constitucionais – art. 5.º, LVII e LXII – e consagrado do Pacto de São José da Costa Rica, art. 8.º). (...) Além disso, no ponto do consentimento, necessária observância de cuidados, a fim de assegurar que este seja consciente e válido. Frise-se que o consentimento não se presume e requer prova, cujo ônus é do Estado (TRF 2.ª Região, RSE 200551015058355, DJ 22.10.2008). Mais do que isso, parece-nos essencial que sejam esclarecidos, ao sujeito da medida e de forma documentada, os seus direitos, o alcance da inviolabilidade do domicílio e as consequências de sua decisão por franquear a entrada de policiais para a busca domiciliar. Trata-se de medidas mínimas para coibir abusos da autoridade policial e fazer valer um Estado Democrático de Direito" (BOTTINI, Pierpaolo Cruz; DELLOSSO, Ana Fernanda Ayres. O consentimento e a situação de flagrante delito nas buscas domiciliares. Disponível em: http://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5199-0-consentimento-e-a-situacao-de-flagrante-delito-nas-buscas-domiciliares. Acesso em 16 jun. 2016) (destaquei).

O que se pondera é justamente que o homem médio brasileiro é profundo desconhecedor de suas garantias mínimas e sente-se coagido diante de tal interpelação policial,

com receio do que pode advir de sua negativa. Nesse mesmo sentido, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro ROGÉRIO SCHIETTI, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1690854/RJ: "Por fim, merece destaque a afirmação constante dos autos de que, ao se dirigirem para a residência, os policiais tiveram a entrada franqueada pela proprietária do imóvel (fls. 3 e 256). Tal realidade, a meu ver, demonstra muito mais uma situação aguda, uma vontade externada sob domínio de intensa pressão, do que uma pouco crível colaboração para que, voluntariamente, fosse autorizado o ingresso de agentes policiais em sua residência para a busca domiciliar".

Tampouco houve visualização de situação de flagrante delito no interior da residência que autorizasse a excepcional entrada no domicílio. Sequer havia droga no interior da residência.

Importante notar que inexistia situação de urgência que inviabilizasse a solicitação de mandado de busca e apreensão, de modo que não havia risco na demora de se aguardar o competente mandado, caso deferido.

Todas as hipóteses descritas no art.5º, inciso XI, da Constituição da República, para ingresso na residência à revelia de consentimento do morador, a qualquer hora do dia ou da noite, estão representadas por um contexto emergencial, baseado na ideia de que seria impossível esperar por um mandado judicial. Basta lembrar que as outras hipóteses são o desastre e o socorro imediato.

Por idênticas razões, a regra será, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o ingresso em domicílio alheio sem consentimento durante o dia com ordem judicial, mesmo nos casos de flagrante delito, salvo nos casos em que existam fundadas razões para a atuação imediata a fim de evitar um mal maior. São as hipóteses em que há risco à vida, à integridade física, risco de desaparecimento de corpo de delito, entre outros. Por outro lado, se o crime permanente e a respectiva situação de flagrante permanente não demandam urgência e admitem que se aguarde por uma ordem judicial, esta deve ser buscada em atenção ao devido processo legal e à garantia da inviolabilidade do domicílio.

Portanto, pelo contexto fático delineado nos autos, não havia elementos concretos que justificassem a invasão de domicílio sem a prévia autorização judicial, valendo destacar, ademais, que não havia urgência que impossibilitasse a solicitação de prévia autorização judicial.

Eis a razão pela qual, dado que a casa é asilo inviolável do indivíduo, desautorizado estava o ingresso na residência do réu, de maneira que as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas.

Portanto, reconheço a nulidade da apreensão de dinheiro, no valor de R\$ 2.707,00, na residência do acusado.

Passo à análise do mérito da ação penal.

Quanto à imputação delitiva, verifico que a materialidade delitiva resultou provada pelo auto de prisão em flagrante (f. 01), boletim de ocorrência policial (f. 06/08), auto de exibição e apreensão (f. 09), laudo de constatação provisória (f. 11/13), laudo de exame toxicológico (f. 105/106), bem como pela prova oral colhida. Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação. Há confissão do acusado, mas referida prova não se encontra isolada nos autos. A prova testemunhal foi firme e coerente, está de acordo com o acervo documental e corrobora integralmente os fatos levados a conhecimento da autoridade policial, à vista do boletim de ocorrência lavrado.

O depoimento dos policiais militares deve ser bem avaliado. É verdade que, sem pretender qualquer crítica, sabe-se que a atuação policial é uma atividade administrativa que se situa em um contexto de tensão de direitos fundamentais, de modo que seria ingenuidade recorrer acriticamente ao dogma da presunção de regularidade dos atos dos agentes dos poderes públicos, confundindo vigência (existência do ato e regularidade formal) com validade (conteúdo material constitucionalmente conformado). Neste sentido, LUIGI FERRAJOLI destaca que "diversamente dos outros ramos da administração pública, é uma atividade em contato direto com as liberdades fundamentais" (Diritto e Ragione. 1998, p. 798, em tradução livre). Entretanto, no caso concreto, os policiais militares apresentaram

versões firmes e coerentes entre si, cujas palavras não estão isoladas nos autos, mas, pelo contrário, respaldadas pelas demais provas. Ademais, não há notícia de conflito ou atrito entre acusado e policiais, seja prévio ou contemporâneo aos fatos. Por tais motivos, os depoimentos prestados pelos policiais militares merecem elevado valor.

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o acusado, deliberadamente, portava droga e não o fazia com o elemento subjetivo específico de consumi-la, o que fica especialmente demonstrado pela confissão e pela quantidade significativa de drogas, sendo pouco crível que consumiria imediatamente aquela quantidade de substância apreendida. Ressalte-se que o acusado trazia consigo 31 pinos plásticos contendo aproximadamente 56,09 gramas de cocaína, além de considerável quantidade de dinheiro.

Ressalte-se que o fato de não ter restado demonstrado a efetiva venda da droga não afasta a tipicidade do delito. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tipo do tráfico de drogas é tipo congruente simétrico, em que o tipo objetivo coincide com o tipo subjetivo, o que significa dizer que não se exige elemento subjetivo específico da mercancia. O tipo do art. 28 da Lei n. 11343/06, este sim, é tipo incongruente, em que o tipo subjetivo está além do tipo objetivo, o que equivale a dizer que se exige a comprovação do elemento subjetivo específico de consumir a droga que porta. Em outros termos, para a condenação no delito do art. 33 da Lei n. 11343/06, e não no art. 28, exige-se tão somente que se afaste, com segurança, a finalidade do consumo próprio, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia (REsp n. 1134610/MG, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 19.08.2010).

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Se a condenação é certa, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

A culpabilidade é normal à espécie. O sentenciado não registra maus antecedentes. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social do sentenciado. Não é possível aferir, quer em sentido técnico ou em sentido vulgar, a personalidade do sentenciado. O motivo da conduta não é especialmente censurável, não sendo senão insito ao crime e, portanto, já valorado pelo legislador no momento da criminalização primária. As circunstâncias são próprias do tipo penal, não sendo especialmente reprováveis. As consequências não são especialmente graves. Não há vítima específica e, portanto, o comportamento da vítima não é elemento aplicável ao delito em apreciação. O acusado foi surpreendido com cocaína, droga especialmente nociva, de modo que a natureza da droga deve ser valorada negativamente. Por fim, a quantidade de droga não excede à normalidade das apreensões nesta comarca. Para cada circunstância judicial valorada negativamente, elevo a pena mínima em 1/8. Havendo uma única circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 5 ano(s), 7 mês(es) e 15 dia(s) de reclusão.

O acusado é primário, conforme certidões de f. 124-125 e 126. O acusado tinha mais de 21 anos à época dos fatos. O acusado confessou os fatos, de forma circunstanciada, além de externar arrependimento. Com estas considerações, seria caso de se atenuar a pena, contudo, observo o que dispõe a Súmula n. 231 do STJ, a qual recomenda que a pena-provisória não pode ser conduzida aquém do mínimo legal. Portanto, a pena-provisória é agora fixada em 5 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão.

O acusado é primário. Não registra maus antecedentes. Não há prova que integre organização criminoso e, ao que consta, envolveu-se com a traficância em episódio isolado, não se dedicando a atividades criminosas. Portanto, faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11343/06. Não vislumbro nos autos elemento apto a evitar que a minorante seja aplicada em seu patamar máximo, de dois terços. Com tais considerações, fixo a pena definitiva ao acusado em 1 ano(s), 8 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão.

Adotando o critério da proporcionalidade entre os limites mínimo e máximo da pena

de multa e os limites mínimo e máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito em tela, fixo a pena de multa em 166 dias-multa, sendo cada dia-multa o equivalente a 1/30 do salário mínimo, o mínimo legal, até porque não comprovada capacidade econômica do(a) acusado(a) que autorize o apontamento de valor mais elevado.

Possível a fixação de regime aberto e substituição por penas restritivas de direito. E isto porque o Supremo Tribunal Federal entende, por seu Plenário, ser inconstitucional o regime inicial necessariamente fechado (HC n. 11840). No mesmo sentido, julgou inconstitucional a vedação à substituição da pena por sanções restritivas de direitos a que se refere o art. 33, § 4º e o art. 44 da Lei n. 11343/06 (HC n. 97256). Por esse motivo, o Senado Federal editou a Resolução n. 05/2012/RSF, suprimindo a proibição à substituição por penas alternativas. Com fundamento no art. 33, § 2º do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada é o regime aberto. Não houve prisão cautelar no curso do processo, motivo pelo qual deixo de aplicar o art. 387, § 2º do Código de Processo Penal.

Preenchidos os requisitos legais, defiro a substituição da pena privativa de liberdade. Em face do montante da pena aplicado, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a seguir especificadas: (i) prestação de serviço a entidade beneficente local, a ser definida oportunamente; e (ii) prestação pecuniária, no valor de 04 (quatro) salários mínimos, valor que deverá ser depositado em conta vinculada ao Provimto CG/TJSP n. 01/2013 para oportuno rateio, mediante depósito na conta judicial n. 2700115060756, agência 2777-4 (Viradouro/SP), Banco do Brasil.

A substituição da pena privativa de liberdade é mais benéfica e, por isso, prejudica a aplicação da suspensão condicional da pena, na forma do art. 77, inciso III, do Código Penal.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização à vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que não houve pedido do Ministério Público ou da vítima nesse sentido, de modo que a condenação seria ofensiva ao contraditório e à ampla defesa.

O(a) acusado(a) responde ao processo em liberdade e não sobrevieram novos fatos ou elementos que pudessem, na forma do art. 316 do Código de Processo Penal, modificar esta situação. Permanecerá, então, em liberdade, até o trânsito em julgado ou pronunciamento em sentido diverso, se motivo para tanto houver.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado VITOR AFONSO DE MELLO RICIOLI, por ter praticado fato tipificado no artigo 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 1 ano(s), 8 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de pena de multa no valor de 166 dias-multa, cada dia-multa fixado no valor de 1/30 do salário mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a seguir especificadas: (i) prestação de serviço a entidade beneficente local, a ser definida oportunamente; e (ii) prestação pecuniária, no valor de 04 (quatro) salários mínimos, valor que deverá ser depositado em conta vinculada ao Provimto CG/TJSP n. 01/2013 para oportuno rateio, mediante depósito na conta judicial n. 2700115060756, agência 2777-4 (Viradouro/SP), Banco do Brasil.

Condeno o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Após o trânsito em julgado:

(a) Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;

(b) Determino o perdimento do dinheiro apreendido em poder do acusado, no valor de R\$ 1610,00, devendo a serventia providenciar ofícios pertinentes para que seja feita sua transferência ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º da Lei 11.343/06.

(c) Quanto ao dinheiro apreendido na residência do acusado, tendo em vista a nulidade da apreensão, determino sua restituição ao acusado, que deverá reclamá-lo no prazo de 90 (noventa) dias. Em caso de inércia, desde já fica decretado o

perdimento em favor da União, na forma do art. 122 do Código de Processo Penal.

(d) Caso exista pena de multa, certifique a Secretaria a existência de fiança nos autos, a qual deverá ser aproveitada para o pagamento da pena de multa e da taxa judiciária, caso não concedida a gratuidade da justiça. Não havendo, ou havendo débito remanescente, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público, na forma do art. 480 das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça, observando-se a desnecessidade de intimação do(a) condenado(a) para pagamento da pena de multa nos autos do processo de conhecimento (CGJ, Processo n. 2014/75969, Parecer n. 108/2022-J);

(e) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

(f) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

(g) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

(h) Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Viradouro, 20 de julho de 2022.

PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA